

1500556-29.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... réu responde a outro processo por tráfico de drogas, o que evidencia que ele se dedicava a atividades criminosas, fazendo do narcotráfico meio de subsistência. Pelos mesmos motivos, o regime prisional deverá ser o inicialmente fechado e se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500556-29.2021.8.26.0571 - Controle 2021/000570

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES

Data da Audiência:

10/02/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Daniel Henrique da Silva Domingues. Ausente a testemunha Bruna Freitas, embora devidamente intimada, consoante fls. 142. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Bruna Freitas, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, pois, no dia 17 de abril de 2021, por volta das 18h15min, na Rua Manoel Humberto Chicoli, 127, Vila Progresso, nesta cidade e Comarca de Itapetininga, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fornecimento ou entrega a consumo, ainda que gratuito, 35 (trinta e cinco) porções de "cocaína", com peso 6,23g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (fls. 94) e apresentou defesa prévia (fls. 98/99). A denúncia foi recebida em 09/06/2021 (fls. 100/101) e o acusado foi pessoalmente citado (fls. 122). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de exibição/apreensão (fls. 16) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 71/73). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu disse que foi abordado pelos policiais e,

indagado, confessou que mantinha drogas no telhado de sua casa. Afirmou que no momento trazia consigo um pino de "cocaína", que seria destinada ao seu próprio consumo (fls. 09). Interrogado em Juízo, o réu disse que trazia consigo R\$ 2,00 em dinheiro e estava indo comprar salgadinho para seu filho. Contou que dois indivíduos estavam fugindo dos policiais, pulando em várias casas. Disse que foi abordado pelos mencionados policiais, que falaram que estaria junto com os furtivos. Contou que os policiais encontraram um pino de "cocaína" no chão e lhe imputaram a propriedade do entorpecente. Narrou que os militares foram até sua residência e ingressaram na habitação sem autorização. Falou que não tinha nada de ilícito em sua residência. Ocorre que a prova oral é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que policiais militares faziam patrulhamento e avistaram o denunciado fazendo contato com o condutor de um veículo. Ao notar a presença policial, DANIEL empreendeu fuga, o que gerou forte suspeita nos policiais e motivou a perseguição e abordagem. Pouco antes de ser detido, o denunciado dispensou uma porção de "cocaína" no solo, que foi recuperada pelos agentes públicos. Durante a revista pessoal foi encontrada a importância de R\$ 2,00 em dinheiro. Indagado, DANIEL confessou que guardava mais drogas em sua residência, no guarda-roupas e no telhado, motivo pelo qual todos se dirigiram para a habitação. Os agentes públicos foram atendidos por Bruna, amásia de DANIEL, que autorizou o ingresso na residência. Nos locais indicados pelo acusado, ou seja, no telhado e no guarda-roupa, foram encontradas mais porções de "cocaína". No telhado, os militares localizaram 04 porções da droga e a importância de R\$ 80,00 em dinheiro, e no guarda-roupa encontraram mais 30 porções e a quantia de R\$ 153,00 em dinheiro. Informalmente aos policiais, DANIEL confessou a traficância. Marcelo Ribeiro da Cruz, policial militar, contou que, durante patrulhamento, avistou o réu fazendo contato com ocupante de um veículo. Disse que o acusado, ao notar a presença policial, deixou o local correndo, o que motivou a abordagem, em uma rua próxima. Questionado sobre o motivo da fuga, DANIEL confessou que estava vendendo um pino de "cocaína" para o ocupante do veículo. Falou que, no momento da abordagem, o réu dispensou um pino de "cocaína". Realizada revista pessoal, encontraram quantia em dinheiro. Questionado se havia mais droga na residência, o réu afirmou que guardava entorpecente no telhado e em um guarda-roupa. Foram até a residência, local em que encontraram 04 pinos de "cocaína" no telhado, além de R\$ 80,00 em dinheiro, e 30 pinos da mesma droga no guarda-roupa, mais R\$ 153,00 em dinheiro. Asseverou que Bruna, amásia do réu, autorizou verbalmente o ingresso na habitação e acompanhou as buscas. No mesmo sentido o depoimento de Renan Siqueira da Silva, policial militar. Como se vê, a prova é firme ao incriminar o acusado. A grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de expressiva quantia em dinheiro, o contato realizado pelo denunciado com o condutor do carro logo antes de ser abordado atestam que as substâncias se destinavam ao tráfico. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas estejam a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. As palavras das testemunhas foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito e, em conjunto com as demais provas, autorizam o decreto condenatório. De mais a mais, as contradições apresentadas durante os interrogatórios policial e judicial também estão a militar contra o acusado. Assim, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu não ostenta maus antecedentes e é primário (fls. 33/36). Ausentes agravantes e causas de aumento de pena. Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu responde a outro processo por tráfico de drogas, o que evidencia que ele se dedicava a atividades criminosas, fazendo do narcotráfico meio de subsistência. Pelos mesmos motivos, o regime prisional deverá ser o inicialmente fechado e se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, com decretação do perdimento do valor apreendido, pois fruto do narcotráfico. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz. O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº

11.343/06 do Código Penal. Ocorre que a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. Senão vejamos. I- DA NULIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR. Inicialmente cumpre notar que parte da materialidade do delito foi obtida por meio de prova ilícita, devendo, pois, ser desconsiderada. Isso porque, de acordo com os policiais ouvidos, a entrada no domicílio do acusado se deu por uma suposta confissão informal, no sentido de que havia entorpecentes na residência, sendo que a companheira do réu supostamente teria autorizado a entrada dos policiais no local. Em primeiro lugar, parece-nos absurdo que uma pessoa, por livre e espontânea vontade, confesse aos policiais que possui substâncias ilícitas em sua residência e convide os agentes a revistar o local. Em segundo lugar, ainda que se considere crível que a companheira do réu autorizou a entrada da polícia na sua residência, não há como se falar que esse é um consentimento válido, autorizador da entrada e posterior revista no domicílio. Aliás, conforme recentemente decidido pelo STJ no HC n. 598.051: a) o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; b) a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Ainda, conforme decisão do TJ-RS, que destacou a invalidade do consentimento de pessoa investigada por tráfico de drogas, o Desembargador relator pontuou: “Não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o art. 5.º, XI, da CF não se infere que poderão ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do morador. Se assim fosse, veríamos-nos diante de um quadro temerário, no qual os mandados de busca e apreensão seriam dispensáveis, já que polícia sempre poderia conseguir, extrajudicialmente, o “consentimento” do proprietário. Afinal, é de se ter em conta que, nas circunstâncias descritas nos autos esse aval foi dado sob constrangimento” (Ap 70058172628, rel. Des. Diógenes V. Hassan Ribeiro, 3.ª Câmara Criminal, DJ 24.06.2014). Dessarte, ainda que houvesse o consentimento da genitora do acusado, duas questões deveriam ser bem refletidas: (i) forma do consentimento; (ii) pessoa que consente e seu grau de esclarecimento sobre as implicações da medida. Sobre a forma do consentimento, deve ser expresso e jamais presumido, sendo que não há previsão legal de forma especial. Ainda, é necessário que aquele que consente tenha pleno conhecimento das circunstâncias e consequências da realização da busca domiciliar, bem como que isso seja documentado. No entanto, isso não aconteceu no caso concreto. Ainda que não exista tal previsão legal específica, tratando-se de medida que pode implicar

a produção de prova contra o próprio morador que consente com a busca, para que ele decida de forma justa e válida se franqueará a entrada em sua residência, necessário que no mínimo lhe sejam esclarecidos seus direitos e o alcance da inviolabilidade do domicílio, bem como as consequências da realização da busca domiciliar. A mesma lógica e o mesmo cuidado são observados nos procedimentos de interrogatórios, tanto judicial quanto policial, a fim de garantir o direito da pessoa de não produzir prova contra si (deriva das previsões constitucionais – art. 5.º, LVII e LXII – e consagrado do Pacto de São José da Costa Rica, art. 8.º). No mais, o argumento de que o tráfico seria crime permanente não é temerário e não autoriza a invasão domiciliar. A autorização para a violação do domicílio, nos casos de flagrante delito, depende de um estado de flagrância claro, constatado antes da invasão do domicílio e passível de demonstração posterior. As suspeitas, fundadas em relatos declarados ou ocultos, devem ser submetidas a prévia autorização judicial, mediante representação. Assim, no caso em discussão, todos os objetos encontrados no interior do imóvel devem ser desconsiderados e não se prestam a provar a materialidade delitiva, não havendo alternativa senão a absolvição do réu, com fundamento no disposto no art. 386, inc. VII, do CPP e em estrita observância ao disposto no art. 5º, art. LVI, da CF e art. 157 do CPP, evitando-se um édito condenatório nulo. II- DA NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO

POR FALTA DE PROVAS. Considerando que as drogas encontradas na residência não se prestam a provar a materialidade do delito, insta salientar que, com relação ao entorpecente supostamente dispensado pelo réu, a denúncia não se sustenta. O policial MARCELO, ouvido em juízo, narrou que viu o réu em atitude suspeita pois estaria em contato com um veículo, o qual teria dispensado um pino de cocaína ao ver a viatura. Prenderam o acusado, que confessou que vendia drogas e que tinha mais drogas na residência. Para ali rumaram, sendo que a companheira do acusado teria autorizado a entrada na residência. Informou que o consentimento da companheira do réu se deu verbalmente. No mesmo sentido foi o depoimento do policial RENAN. O acusado, interrogado sob o crivo do contraditório, negou os fatos. Disse que, no dia do ocorrido, ocorria uma perseguição policial com relação a outros sujeitos e acharam um pino de cocaína na rua, tendo imputado a posse a ele. Em seguida, os policiais invadiram sua casa, pressionaram sua esposa e disseram que acharam droga no local. Assim, com relação à cocaína que supostamente foi dispensada pelo réu não há qualquer prova que se destinasse à venda: ao contrário, tudo indica que se tratava de entorpecente para uso. Ainda que se considere crível que o réu tenha dispensado algo e que tivesse, de fato, entorpecentes em sua residência, isso não é, obviamente, conclusão, por si só, de que ele praticasse o tráfico de entorpecentes. No mais, quanto aos demais entorpecentes apreendidos na residência, conforme exposto no tópico 1, deverão ser afastados dos autos. Assim, havendo dúvidas acerca da prática delitativa, o que atrai a incidência do princípio in dubio pro reo, deve o acusado ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III- DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11343/06: Com relação ao pino de cocaína que, supostamente, foi dispensado pelo réu, a acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta quantidade entorpecentes e como o réu não foi preso mantendo contato com pessoas, mas apenas – de acordo com os depoimentos – na posse de pequena quantidade de entorpecente, dentro de seu veículo, a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. Aliás, o próprio réu esclareceu que se trata de usuário e que o entorpecente apreendido era para seu uso. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico “para consumo pessoal”. Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presuma que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Ainda, o fato de as substâncias estarem embaladas individualmente nada indica: se alguém vende a droga fracionada, alguém a compra também fracionada, de modo não há como inferir a mercancia apenas em razão desta circunstância. Destaque-se, por fim, que o réu declarou que possuía os entorpecentes para seu consumo pessoal. De fato, o caso envolve diminuta quantidade de entorpecente, indicando se tratar de hipótese de uso. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais.

IV- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes

seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. V- TESES SUBSIDIÁRIAS – Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer: i) fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, considerando que a culpabilidade do acusado não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal; (ii) seja fixado o regime semiaberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, “b”, § 3º, do CP, bem como considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e da súmula nº 440 do E. STJ; (iii) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP) – art. 387, § 1º, do CPP, requerendo, subsidiariamente, a substituição da prisão por uma das cautelares arroladas no art. 319 do CPP. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. DANIEL HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de abril de 2021, por volta das 18 h e 15 min, na Rua Manoel Humberto Chicoli, n. 127, Vila Progresso, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta e cinco porções de cocaína, com peso de 6,23 gramas. Notificado, fls. 94, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 98/99. A denúncia foi recebida, fls. 10/101, e o Réu, citado, fls. 122. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas presentes e realizou-se o interrogatório (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a absolvição e, de forma subsidiária, a desclassificação. É o relatório. DECIDO. Afasto a preliminar. Segundo o art. 5º, inciso XI, a casa é asilo inviolável, salvo em caso de flagrante delito ou durante o dia, por determinação Judicial (grifo nosso). Portanto há autorização para ingresso em residências durante o dia ou noite em caso de flagrante delito. Segundo disposição do art. 283 “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”. Oportuno ressaltar que os policiais não ingressaram na residência sem qualquer informação, de forma aleatória; tinham eles abordado o Réu na rua, com dinheiro e entorpecentes, bem como colhido a informação do próprio Acusado no sentido de que no apartamento havia mais entorpecentes. Assim, havia fundada suspeita para a abordagem e vistoria da casa, onde, de fato, encontraram entorpecentes destinados ao comércio, em situação de flagrante delito, na medida em que o crime de tráfico de entorpecentes é permanente. O caso concreto se amolda ao permissivo constitucional. Por fim, os policiais asseveraram que Bruna, amásia do Réu, tinha permitido o ingresso na residência. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 13/15, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 16, no Laudo de Constatação, fls. 19/20, bem como no Exame químico-toxicológico n. 123032/2021,

fls. 71/73, constatando-se a presença do princípio ativo cocaína. Marcelo Ribeiro da Cruz e Renan Siqueira da Silva, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento quando presenciaram o Réu manter contato com um motorista; ele, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga, mas os policiais foram atrás e conseguiram alcançá-lo, quando ele dispensou uma porção de "cocaína"; em revista localizaram com o Acusado a quantia de R\$ 2,00; ele admitiu o comércio de entorpecentes e disse que na casa havia mais drogas; na residência do Réu foram atendidos por sua amásia, que franqueou a entrada dos policiais, que encontraram, no telhado e no guarda-roupa, outras porções de entorpecentes e dinheiro. Daniel Henrique da Silva Domingues, Réu, ao ser interrogado, disse que tinha saído com R\$ 2,00 no bolso para comprar salgadinho para seu filho, quando a viatura passou atrás de um indivíduo que pulou duas casas; depois o Acusado foi abordado, não havia drogas, mas encontraram um pino dispensado pela outra pessoa que tinha passado correndo e disseram que era dele; depois foram à sua casa, lá não havia entorpecentes. Estavam a esposa, a irmã e seu filho. Confrontando-se a prova coligida, é inconteste que o Réu era o proprietário das drogas, destinadas à venda, pois outra conclusão não se chega após a análise das circunstâncias. Ora, os policiais viram o Réu em via pública, por volta das 18 h e 15 min, em local conhecido pela venda de drogas, e, ante a fuga, fizeram a abordagem, oportunidade em que localizaram uma porção de "cocaína"; indagado, admitiu que na casa havia mais entorpecentes, então para lá rumaram, onde outras porções foram apreendidas, além de dinheiro, fruto de vendas pretéritas, o que se infere das circunstâncias e da ausência de demonstração lícita. A finalidade mercantil é clara ante a quantidade, a forma de embalagem, o número de porções e até mesmo o local, e, ademais, não é crível que o Réu fosse utilizar todo o entorpecente. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo, mantinha em depósito e guardava substância entorpecente, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, manter em depósito e guardar, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do Agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero as circunstâncias judiciais favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena - base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: A agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "j", não pode ser acolhida. Com efeito, a incidência da agravante da calamidade pública exige que o agente tenha se aproveitado consciente e voluntariamente de circunstância que implique maior gravidade, e não há nexo de causalidade entre a ofensa ao bem jurídico e a pandemia do novo coronavírus. O Réu é menor de 21 anos, logo faz jus a atenuante. Todavia, na segunda etapa, a atenuante não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Art. 68, do CP: Não há. Considerando-se a quantidade de

entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa "empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo", pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar DANIEL HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Decreto a perda dos valores. Deixo de condenar o Ré nas custas, ante a pobreza presumida. O Réu respondeu em liberdade ao processo, e, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 10 de fevereiro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA